

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제07절 소제기의 효과>

[기출][2023-1-1]상계의 항변과 중복소송의 관계 및 전소와 후소의 선후에 따른 대여금채권 소구의 적법성

《【문제1】 甲은 乙을 피고로 매매대금채권 5천만 원의 지급을 구하는 소(이하, A소라 한다)를 제기하였다. 이 소송에서 乙은 甲에 대하여 갖고 있는 대여금채권 6천만 원(이하, 이 사건 대여금채권이라 한다)을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하였다. 다음 물음에 답하시오. (다만, 아래의 각 물음은 독립적임) (50점)

(물음1)

i 상계의 항변을 주장한 乙은 A소 계속 중 이 사건 대여금채권을 소구채권으로 하여 甲을 피고로 하는 대여금반환을 구하는 소(이하, B소라 한다)를 제기하였다. 乙이 제기한 B소는 적법한가?

ii 만일 甲이 제기한 A소 계속 전에 乙이 이 사건 대여금채권의 반환을 구하는 소(C소라 한다)를 제기하였다면, 乙은 그 후 제기된 甲의 A소에서 이 사건 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장할 수 있는가? (20점)》

<문제1의 물음1> 상계의 항변과 중복소송의 관계 및 전소와 후소의 선후에 따른 대여금채권 소구의 적법성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 제기한 매매대금청구소송(A소)에서 乙이 자신의 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장한 상태에서 동일한 대여금채권으로 별소(B소)를 제기하거나, 반대로 대여금반환청구소송(C소)이 먼저 계속 중인 상태에서 후소인 A소에서 상계의 항변을 주장한 상황이다. 쟁점으로 <상계항변과 별소 제기가 민사소송법상 중복소제기금지에 저촉되는지, 선행소송 계속 중 후소에서 동일 채권을 자동채권으로 한 상계항변이 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 B소의 적법성 및 C소 계속 중 A소에서 상계항변의 허용 여부를 답한다.

II. 상계의 항변과 중복소송에 관한 법리

1. 중복소송의 금지 [민사소송법 제259조]

(1) 의의 및 요건

- 법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다. 이는 판결의 모순·저촉을 방지하고 피고의 이중 응소 부담 및 법원의 소송경제적 낭비를 막기 위함이다. 중복소송이 성립하기 위해서는 당사자의 동일성, 소송물의 동일성, 전소의 계속이라는 요건을 충족하여야 한다.

(2) 소송물 동일성의 판단

- 소송물은 청구취지와 청구원인에 의해 확정되는 소송의 대상을 의미한다. 소송물이 완전히 일치하는 경우뿐만 아니라, 전소와 후소의 청구가 서로 반대관계에 있거나 모순·저촉되는 관계에 있는 경우에도 소송물의 동일성이 인정된다.

2. 상계의 항변 주장 후 별소 제기 (물음1- i 관련 법리)

(1) 학설의 대립

① 중복소송설 (긍정설)

- 상계의 항변이 판단되는 경우 민사소송법 제216조 제2항에 따라 기판력이 발생하므로, 별도의 소를 제기하는 것은 중복소송 금지에 위배되어 부적법하다고 보는 견해이다.

② 별소허용설 (부정설)

- 상계의 항변은 소송물이 아닌 방어방법에 불과하므로 전소의 계속 중에 동일한 채권으로 별소를 제기하더라도 소송물의 동일성이 없어 중복소송에 해당하지 않는다고 보는 견해이다.

(2) 판례의 태도

- 대법원은 상계의 항변은 법원의 판단을 요하는 방어방법에 지나지 않아 소송물 자체가 될 수 없으므로, 전소에서 상계의 항변을 제출하였다 하더라도 그 후 동일한 대여금채권으로 제기한 후소(별소)는 중복소송에 해당하지 않아 적법하다고 판시하였다.

3. 별소 제기 후 상계의 항변 주장 (물음1- ii 관련 법리)

(1) 학설의 대립

① 상계항변 허용설

- 소의 제기과 상계의 항변은 성격이 다르며 당사자의 방어권을 보장하기 위해 선행 소송이 있더라도 후행 소송에서의 상계의 항변은 허용되어야 한다는 견해이다.

② 상계항변 불허설

- 전소에서 이미 소송물로 삼은 채권을 후소에서 다시 상계의 항변으로 삼는 것은 사실상 동일한 채권에 대하여 이중의 사법적 판단을 구하는 것이며, 모순·저촉의 위험을 초래하므로 허용되지 않는다는 견해이다.

(2) 판례의 태도

- 대법원은 이미 대여금반환 청구의 전소(C소)를 제기한 자가 후소(A소)에서 동일한 채권을 자동채권으로 삼아 상계의 항변을 주장하는 것은, 전소와 후소에서 이중으로 판단이 내려짐으로써 판결의 모순·저촉을 초래할 우려가 있고 판결의 기판력 범위(제216조 제2항)와 저촉될 수 있으므로 허용되지 않는다고 판시하였다.

III. 사안의 적용

1. 물음1- i의 적용

- 사안에서 전소인 A소의 소송물은 甲의 매매대금채권이고, 乙의 대여금채권은 상계의 항변이라는 단순한 방어방법으로 제출되었다. 따라서 乙이 동일한 대여금채권을 소송물로 하여 제기한 후소인 B소는 전소인 A소와 소송물이 동일하지 않다. 대법원 판례의 태도에 따를 때 상계의 항변은 중복소송 금지 조항의 적용을 받지 않으므로, 乙이 제기한 B소는 적법하다.

2. 물음1- ii의 적용

- 乙은 이 사건 대여금채권의 지급을 구하는 전소인 C소를 제기하여 소송계속을 발생시켰다. 이 상황에서 乙이 후소인 A소에서 동일한 대여금채권을 자동채권으로 삼아 상계의 항변을 제기하는 것은 이미 소송물로 법원에 계속되어 있는 대여금채권에 대하여 이중으로 법원의 판단을 구하는 것이다. 이는 중복소송금지 원칙의 취지(유추적용) 및 기판력의 모순·저촉 방지 원칙에 위배되므로 乙은 상계의 항변을 제기할 수 없으며, 법원은 이를 배척하여야 한다.

IV. 결론

1. 물음1- i 의 결론

- 乙이 A소 계속 중 이 사건 대여금채권을 소구채권으로 하여 제기한 B소는 소송물의 동일성이 없어 중복소송에 해당하지 않으므로 전적으로 적법하다.

2. 물음1- ii 의 결론

- 乙이 이미 C소를 제기한 후 제기된 A소에서 이 사건 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하는 것은 판결의 모순·저촉을 유발하는 무효한 주장이므로 이를 주장할 수 없다.